

1500599-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Rés:

LEILIANE PEREIRA DA CUNHA e THAIS JANAÍNA DO PRADO

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

LEILIANE PEREIRA DA CUNHA e THAIS JANAÍNA DO PRADO, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1500599-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500599-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Rés:

LEILIANE PEREIRA DA CUNHA e THAIS JANAÍNA DO PRADO

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

LEILIANE PEREIRA DA CUNHA e THAIS JANAÍNA DO PRADO, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal, porque, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 23h30, em ocasião de calamidade pública, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, nº 01, Sé, nesta cidade e comarca da Capital/SP, previamente ajustadas e com unidades de desígnios e propósitos, vendiam e traziam consigo, para fins de traficância, drogas consistentes em 10 (dez) invólucros contendo a substância lança-perfume, com peso líquido de 100 ml (cem mililitros); 67 (sessenta e sete) porções de cocaína, com peso líquido de 35,6 g (trinta e cinco gramas e seis decigramas); e 25 (vinte cinco) porções de maconha, com peso líquido de 40,8 g (quarenta gramas e oito decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, possuíam a quantia de R\$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) em dinheiro (fls. 94/96). Em 06 de janeiro de 2022, LEILIANE e THAIS tiveram as prisões flagranciais convertidas em preventiva (fls. 64/67).

A denúncia foi recebida (fls. 107/109), as acusadas foram citadas e notificadas (fls. 145/146 e 147/148) e apresentaram Resposta à Acusação (fls. 153/154). Indeferiu-se, em 11 de abril de 2022, o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa técnica das acusadas (fls. 143/144).

Ratificado o recebimento da inicial acusatória (fl. 155).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns e as rés foram interrogadas (fls. 164/167).

Sobreveio decisão liminar nos autos do Habeas Corpus nº 2085610-33.2022.8.26.0000 deferindo, parcialmente, o pedido de liberdade às acusadas, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal (fls. 176/179).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação das rés, nos exatos termos da denúncia (fls. 164/166).

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois, em que pese a confissão de ambas as acusadas, o conjunto probatório mostra-se frágil. Subsidiariamente, requereu i) a fixação das bases nos mínimos; ii) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal; iii) o reconhecimento da atenuante da confissão a ambas; iv) a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 em sua fração máxima; v) a detração penal; vi) fixação do regime aberto; vii) a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos; viii) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 166/167).

O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ratificou a liminar deferida e concedeu parcialmente a ordem nos autos do Habeas Corpus nº 2085610-33.2022.8.26.0000 para "substituir a prisão preventiva das pacientes pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal" (fls. 401/405).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação das acusadas.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo(s) Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Termos de Depoimentos (fls. 08, 09 e 10), Termos de Interrogatórios (fls. 11 e 12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25/26), Laudo de Constatação (fls. 27/30), Relatório Final (fls. 40/41) e, sobretudo, pelo Laudo Químico-toxicológico Definitivo (fls. 161/163).

A autoria dos crimes ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

Anderson Douglas Valentim de Castro, policial militar, contou que estava juntamente de seu companheiro de farda efetuando patrulhamento pela região dos fatos e abordaram um indivíduo; localizaram "entorpecente" com o homem. Foram informados pelo sujeito que ele havia comprado a droga em uma "barraca próximo do local da abordagem, na Praça Pacheco". Com as informações sobre as características do local e "de quem teria vendido para ele", dirigiram-se até o lugar apontado pelo usuário de drogas, e encontraram as "duas mulheres, conforme as características que ele passou". Elucidou que, no ato da abordagem, uma das rés "estava bem na entrada de uma barraca, e a outra estava do lado de fora". Não efetuaram a busca pessoal nas mulheres. As acusadas traziam consigo drogas, do lado de fora da barraca; ambas informaram a existência de mais entorpecentes no interior da barraca, a qual aparentava ser utilizada para dormirem. Especificou que as acusadas, no ato da diligência, alegaram que as drogas eram "de um homem, que morava no Glicério, que repassava para elas venderem lá no local". Não conhecia as rés. Não chegou a presenciar a mercancia ilícita de drogas com relação ao usuário detido anteriormente. O usuário de drogas "chegou a apontar" para as acusadas - "é aquelas duas que tá ali, sentadas ali"; posteriormente, o rapaz confirmou, na viatura policial, que as acusadas eram as vendedoras de drogas. Localizaram com as rés, "se eu não me engano", "lança-perfume, cocaína e maconha, e dois smartphones".

O policial militar Carlos do Carmo Júnior prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Anderson. Acrescentou que puderam visualizar a

mercancia ilícita envolvendo o usuário detido e as acusadas - "quando eles notaram a presença da viatura, ambos se dissiparam né, e nós realizamos inicialmente a abordagem do indivíduo do sexo masculino". Após breve "entrevista", o usuário confirmou que havia adquirido "lança-perfume" diretamente das acusadas. Não conhecia as rés. LEILIANE "informou, também, que parece que era o segundo dia que ela estava trabalhando, fazendo tráfico de drogas naquela região". As rés, por si sós, "pegaram" e entregaram as drogas que estavam dentro da barraca. Assinalou que houve apreensão de dinheiro - "trezentos e alguma coisa, trezentos e sessenta e oito, alguma coisa assim", "fracionado". Foram informados pelas acusadas que o responsável pelo recolhimento do dinheiro já havia passado e recolhido a quantia referente à venda de drogas efetuada durante a noite.

Em solo policial, as acusadas assumiram informalmente a prática delitiva (fls. 11 e 12).

Em juízo, LEILIANE e THAIS confessaram a traficância.

LEILIANE elucidou que "o policial não presenciou a venda" de drogas. Os policiais estavam próximos do local onde estava com THAIS, "quando abordaram o rapaz" - "ele estava algemado, sentado de costas para nós". O usuário indicou que, de fato, estava vendendo drogas em companhia de THAIS. Asseverou que era a segunda vez que praticava a mercancia de entorpecentes. É usuária de drogas e precisava alugar outro imóvel para morar; estava sendo despejada e tinha vergonha de pedir dinheiro a sua genitora. Foi convidada pelos "menores" do ponto de tráfico a vender drogas para "ganhar dinheiro"; aceitou, pois estava precisando. Foi presa em seu segundo dia de traficância. As drogas estavam no interior da barraca, bem como consigo e com THAIS. Não sabe a origem das drogas que lhes eram entregues. Estavam com certa quantia em dinheiro no momento da prisão. Está muito arrependida; sempre trabalhou honestamente.

THAIS acredita que os policiais visualizaram a venda de drogas para o indivíduo que fora detido. Não acredita que o usuário tenha apontado que estivesse vendendo drogas com LEILIANE, mas sim que os policiais decidiram pela abordagem porque estavam paradas na frente da barraca vendendo os entorpecentes - "eles tavam distante do outro lado da rua, de olho". Confirmou que estavam vendendo drogas no local - "duas vezes só que a gente estava lá". Está arrependida. Cometeu o crime por "necessidade" e "desespero".

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar as acusadas pelo crime a elas imputado na denúncia.

Por primeiro, as acusadas confessaram a traficância, o que foi corroborado pelos depoimentos seguros dos policiais que procederam ao flagrante e realizaram a apreensão das drogas, dos celulares e do dinheiro.

Veja-se que, aliado aos depoimentos dos policiais, a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e o local em que as rés estavam já são suficientes para caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando provada a origem espúria da quantia apreendida. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória. (RESP nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

É de asseverar, ainda, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que pequenas divergências em seus relatos, normais em virtude de participarem de várias diligências semelhantes, não retiram o

valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados.

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Pontue-se, porquanto oportuno, que a condição de dependente químico não tem o condão de excluir automaticamente o enquadramento típico do crime de tráfico de drogas, notadamente porque, em grande parte dos casos, os usuários de entorpecentes, infelizmente, praticam a mercancia ilícita para conseguirem sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJ TJ 101/498).

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

1) Da ré LEILIANE PEREIRA DA CUNHA:

Possui 35 (trinta e cinco) anos. Manteve relacionamento afetivo com THAIS durante 07 (sete) anos. Tem 04 (quatro) filhos - "um de vinte, um de quatorze, um de treze, e outro de dez". Sua mãe possui aproximadamente 58 (cinquenta e oito) anos. No momento, sua filha mais nova e seu filho mais velho vivem com sua genitora; os filhos "do meio" residem com a avó paterna. Trabalha como diarista e como garçonne; estava há 02 (dois) meses desempregada. Ganhava R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês; pagava R\$ 600,00 (seiscentos reais) de aluguel; vivia com THAIS e sua filha caçula. Seus filhos estudam; o mais velho trabalha no comércio de sua genitora. Reside no Glicério. Nunca foi processada.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de LEILIANE, a qual assumiu a prática delitiva em juízo. Nada obstante, as sanções permanecem inalteradas, porquanto elas já se encontram nos patamares, nos termos da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento da i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que LEILIANE aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]". (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na terceira etapa, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício.

Observando-se o critério da proporcionalidade e razoabilidade no caso em questão, tem-se que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que LEILIANE é tecnicamente primária e tem bons antecedentes. Resta, portanto, sua pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

2) Da ré THAIS JANAÍNA DO PRADO:

Possui 23 (vinte três) anos. Era casada com LEILIANE. Não possui filhos. Sua mãe tem por volta de 49 (quarenta e nove) anos e seu pai aproximadamente 46 (quarenta e seis) anos; tem 03 (três) irmãos, uma irmã de "vinte seis", um irmão de "vinte quatro" e outra de "doze". Estudou até a 7ª Série. Fazia bicos em um bar de seu amigo. Ganhava aproximadamente R\$ 1.000,00 (mil reais) por mês. Morava com sua família, em uma casa alugada, no Glicério, próximo a casa da mãe de LEILIANE; pagava aluguel de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Nenhuma pessoa dependia

economicamente de seus rendimentos. Nunca foi processada.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de THAIS, a qual assumiu a prática delitiva em juízo. Nada obstante, as sanções permanecem inalteradas, porquanto elas já se encontram nos patamares, nos termos da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento da i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que THAIS aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na terceira etapa, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. Observando-se o critério da proporcionalidade e razoabilidade no caso em questão, tem-se que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que THAIS é tecnicamente primária e tem bons antecedentes. Resta, portanto, sua pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Sobre a redução das penas das acusadas deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: "Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda" (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento.

Por conseguinte, excepcionalmente, considerando as particularidades do caso vertente, substituo a pena privativa de liberdade de LEILIANE e THAIS por 02 (duas) restritivas de direitos, em consonância com o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade preferencialmente voltada ao auxílio de dependentes químicos, a ser indicada na fase de Execução.

Em caso de descumprimento das penas alternativas e conversão em penas privativas de liberdade, o regime inicial para cumprimento das penas será o aberto.

Importante ressaltar que o tráfico privilegiado não é definido como crime hediondo, conforme art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal e, portanto, os efeitos decorrentes da hediondez de um delito não são aplicáveis, sendo plenamente possível o regime inicial em modalidade diferente da fechada.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar:

1) LEILIANE PEREIRA DA CUNHA, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade preferencialmente voltada ao auxílio de dependentes químicos, a ser indicada na fase de Execução.

2) THAIS JANAÍNA DO PRADO, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, sendo prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado na fase de Execução, e o pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade preferencialmente voltada ao auxílio de dependentes químicos, a ser indicada na fase de Execução.

As sentenciadas poderão recorrer em liberdade, ante a natureza das sanções aplicadas.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos. Oficie-se. Adite-se a carta de guia, se necessário, elaborando-se o cálculo da pena de multa aplicada.

Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União, conforme o artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

As rés ficam dispensadas do recolhimento das custas processuais, vez que assistidas pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se os nomes das sentenciadas no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA